

1507352-95.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1507352-95.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507352-95.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082980/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 16981411 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 1270/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2082980 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DE SOUZA SANTOS e outro

VISTOS.

DIEGO DE SOUZA SANTOS e DANIEL FILIPE DE MORAES BATTAGGIA, qualificados nos autos,

estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2021, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Rua Hipólito de Camargo, altura do nº 10, Guaianases, nessa cidade e comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de desígnios, traziam consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 84 (oitenta e quatro) porções de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 187,3g (cento e oitenta e sete gramas e três decigramas), 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 24g (vinte e quatro gramas), e 80 (oitenta) porções da mesma substância, sob a forma de "crack", com peso líquido de 11g (onze gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2021 (fls. 138/139), os réus foram citados (fls. 150/151), e apresentaram defesa preliminar (fls. 157).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e de defesa, sendo os réus interrogados (fls. 176/178 e 232/233).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 237/247). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, reconhecimento da confissão, afastamento da agravante, reconhecimento da menoridade relativa do réu Daniel, regime aberto ou diverso do fechado para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 250/268).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de DIEGO DE SOUZA SANTOS e DANIEL FILIPE DE MORAES BATTAGGIA, porque praticaram o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, auto de constatação de fls. 25/28 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 140/142, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína e Tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com os réus.

Interrogado, o réu Daniel Filipe de Moraes Battaggia negou a prática do crime. Disse que estava na casa de sua namorada e sua mãe adotiva lhe chamou para que levasse seu irmão até a casa de sua avó. Depois, um amigo lhe chamou para fumar narguile, sendo que convidou também Alessandra. Estava atravessando a passarela e viu o réu Diego, que conhecia apenas de vista. Foi com Alessandra até um ponto de ônibus e enquanto ela foi até uma loja, acabou sendo abordado pelos policiais e conduzido até a passarela novamente. Outras pessoas foram abordadas, mas acabaram sendo liberadas, ao passo que foi conduzido à Delegacia. Os policiais pularam para a linha do trem e pegaram uma sacola azul, mas desconhecia seu conteúdo. Consigo havia apenas um bilhete único, vinte reais e uma máscara branca. Não conhecia os policiais até então. Naquela passarela onde estava o corréu existe um ponto de venda de drogas, mas não frequentava aquele local, apesar de fumar "maconha", pois o local era próximo da casa de sua avó. Na época trabalhava esporadicamente num lava rápido de um amigo seu, em Ferraz.

Também interrogado, o réu Diego de Souza Santos admitiu a prática do crime. Disse que no local existe um albergue e costumava frequentar tanto o albergue, quanto o ponto de venda de drogas. Naquela data estava usando droga com um colega e foi ao local para buscar mais entorpecentes. Havia entregado uma nota de cinquenta reais,

mas os traficantes disseram que a nota seria falsa. Disse que não tinha mais dinheiro, então eles falaram que deveria atuar na função de “olheiro” para cobrir esse valor. Quando os policiais chegaram, eles fecharam a passarela e abordaram diversas pessoas, inclusive pessoas que estavam aguardando para entrar no albergue. Não viu se os traficantes foram abordados, pois eram muitas pessoas, e o corréu só viu posteriormente. Não o tinha visto naquela noite, antes da abordagem. Já havia sido abordado pelos policiais, mas nunca tinha sido preso por eles.

Nada obstante o réu Daniel não ter admitido a participação no tráfico, a autoria restou demonstrada em relação a ambos os réus.

Com efeito, o policial militar Thiago Milani atestou que estavam em patrulhamento e o local dos fatos era o início de uma passarela, na antiga estação de Guaianases. Viu o réu Diego dispensando um saco e empreendendo fuga, enquanto o réu Daniel permaneceu no local. Desembarcaram e conseguiram abordar a ambos, sendo que o réu Daniel estava com dinheiro. O réu Diego admitiu informalmente a prática do tráfico. Não se recordou exatamente quais eram os entorpecentes apreendidos. Explicou que nenhum dos réus se declarou usuário e que no momento em que os avistou ambos estavam parados, um ao lado do outro. Não os conhecia até então.

Já o policial militar Rafael Mauro Maceno atestou que se recordava vagamente dos fatos. Estavam em patrulhamento e avistaram os réus numa passarela, onde existe um ponto de tráfico. Ao perceberem a presença policial, eles demonstraram nervosismo e um deles saiu correndo, enquanto o outro saiu andando, sendo que conseguiram abordá-los. Um deles estava com as drogas e o outro com certa quantia em dinheiro, mas não se recordou a quais eram as drogas e tampouco a quantia de dinheiro apreendida. Inicialmente eles negaram a prática do crime, mas depois acabaram admitindo o seu cometimento, dizendo que precisavam do dinheiro para sustentar as famílias. No momento da abordagem não havia outras pessoas próximas a eles.

Por fim, a testemunha de defesa Alessandra Hilary Domingues Macedo dos Santos disse ser namorada do réu Daniel, conhecendo-o desde dezembro de 2020. Não conhece o corréu Diego. Contou que encontrou-se com o réu e saíram para levar o irmão dele até a casa da avó. Chegaram em Guaianases por volta das 19:00 ou 20:00 horas e saíram de lá por volta das 21:00. O réu queria visitar a casa de um amigo dele, porém, quando foi ver o preço de produtos numa loja, o acusado saiu de perto de si e não mais o encontrou. Então, voltou à casa da avó dele, onde contou o ocorrido para a mãe de Daniel, que ficou preocupada. Só no dia seguinte ficou sabendo que ele havia sido preso, após contato que uma ex-namorada dele realizou com a família do acusado. Não sabe se o réu Daniel conhece ou tem amizade com o corréu Diego.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o depoimento dos policiais merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Ademais, há que se notar que as versões apresentadas pelos acusados não são coerentes nem mesmo entre elas. O réu Daniel relatou ter visto o acusado Diego quando passou pelo local, não sendo crível que o réu Diego não o tivesse visto, uma vez que relatou que exercia a função de campana, ou seja, deveria justamente estar atento às pessoas que passavam pelo local.

Também a alegação do réu Diego de que diversas pessoas foram abordadas pelos policiais, mas não teria conseguido ver se os supostos traficantes também foram

abordados não se mostra razoável, na medida em que afirmou que deles recebeu a tarefa de avisá-los quando da aproximação da polícia.

Aliás, de se ressaltar que também a própria versão de que traficantes teriam lhe confiado, de uma hora para a outra, a tarefa de observar a chegada ou não de policiais no local, não merece crédito, já que o local é conhecido como ponto de venda de droga.

Por outro lado, o depoimento da testemunha Alessandra, no cotejo das provas, não pode prevalecer em face dos depoimentos prestados pelos policiais militares, uma vez que era namorada do acusado e nitidamente possui interesse em sua absolvição. Além do que, afirmou que estava junto de Daniel, quando de repente ele se afastou, não sabendo dizer para onde teria ido. Ora, se ambos passaram pela ponte, para chegar ao local onde dele se perdeu, evidente que Alessandra, ao retornar para a residência de familiares dele, de onde tinham se despedido, por certo teria visualizado sua prisão, já que ocorrida na mesma ponte que deveria utilizar para o trajeto. Todavia, nada disso testemunhou.

Portanto, a versão que os réus apresentaram para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos.

Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportaram ao avistar a viatura, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da confissão realizada pelo réu Diego e em face da menoridade relativa do réu Daniel.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. Os réus não demonstraram possuir atividade lícita, com eles foram apreendidos R\$ 237,00, sem qualquer comprovação de origem lícita, restando evidente que se dedicam à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, atentando-se à quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, inclusive cocaína, na forma de "crack", de natureza mais nociva, sendo sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros, o mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L". Óbvio, portanto, que para o cometimento do crime em questão é necessário estar envolvido, ainda que minimamente, com toda a cadeia criminoso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO DIEGO DE SOUZA SANTOS e DANIEL FILIPE DE MORAES BATTAGLIA, qualificados nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder aos réus qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderão apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva dos sentenciados. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e recomendem-se na prisão em que se encontram.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de janeiro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA